

1500056-19.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro ou o reconhecimento do tráfico privilegiado; aplicação da atenuante de menoridade penal preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de Drogas; causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-19.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000020

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

João Paulo de Assis

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

JOÃO PAULO DE ASSIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 14 horas e 11 minutos, na Avenida Benedito Friggi, nº. 100, bairro Jardim Nova Detroit, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 24 (vinte e quatro) porções da droga Cannabis sativa L., conhecida como maconha, com massa líquida de 68,6g (sessenta e oito e seis centigramas); 75 (setenta e cinco) porções da droga cocaína na forma de pedra “crack”, com massa líquida de 40,5g; (quarenta gramas e cinco) centigramas) e 78 (setenta e oito) porções da droga cocaína em forma de pó, com massa líquida de 136,8g (cento e trinta e seis gramas e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/34, fotografias de fls. 36/38, laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 39/44 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 92/95.

Devidamente notificado (fls. 117), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 120/167).

Recebida a denúncia (fls. 203/205), o réu foi citado (fls. 239).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em memoriais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena. No tocante à dosimetria, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas; não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06; fixação de regime inicial fechado; não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, postulou a decretação do perdimento da motocicleta apreendida (fls. 345/357).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição sumária do acusado por estar comprovado: que ele não concorreu para infração penal; não existir prova de ele ter concorrido (de alguma forma) para a infração penal; existirem circunstâncias que excluam e isentam ele da prática de crime; não existir provas suficientes para condenação do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro ou o reconhecimento do tráfico privilegiado; aplicação da atenuante de menoridade penal preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de Drogas; causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos e recurso em liberdade (fls. 362/435).

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 03/08, auto de exibição e apreensão de fls. 33/34, laudo de constatação provisória de fls. 39/44 e laudo de exame químico-toxicológico fls. 92/95, com resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria do tráfico ficou seguramente caracterizada em relação ao réu.

Interrogado em solo policial (fls.10), João Paulo relatou que foi abordado em frente à sua casa em dezembro de 2020 pelos mesmos policiais que o abordaram no dia dos fatos, naquela ocasião por não possuir habilitação veicular. Teve uma segunda fuga deles pelo mesmo motivo. Na data dos fatos, quando saía da casa de uma amiga, em um cruzamento, colidiu contra a motocicleta de um destes policiais militares. Por temer as ameaças recebidas destes policiais, após a primeira fuga, na qual eles, na frente de sua mãe e de sua irmã, ameaçaram de o "ensapar" no caso de nova fuga, empreendeu fuga novamente com a sua motocicleta. Após ser abordado e revistado, os policiais citaram que não deixariam "passar" dessa vez. Negou que tinha drogas ou qualquer envolvimento com o tráfico.

Em juízo o réu disse que uma vez foi abordado e liberado pelos policiais. Depois disso deu "duas fugas" nos policiais e que eles mandaram recado por seus amigos que iriam pegá-lo. No dia dos fatos foi abordado e agredido, sendo que nada de ilícito trazia em seu poder, tampouco em sua moto. Disse que tinha perdido as placas da moto.

A negativa do réu é desprovida de credibilidade.

Com efeito, os policiais militares Wesley e Jefferson, ouvidos em solo policial (fls. 09 e 10) e em juízo, narraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento pela região, quando se depararam com o acusado em uma motocicleta sem placas no contrafluxo. Ele tentou fugir, porém foi cercado. Ao avistá-los, o réu jogou a motocicleta que conduzia contra o policial Jefferson, que caiu da moto e se machucou. Em seguida, empreendeu fuga, sendo acompanhado pelo policial Wesley. Após perder o controle da motocicleta e cair, João foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Em revista veicular, foi constatado que a motocicleta estava sem emplacamento e, no interior da carenagem, foi localizada uma sacola com 78 pinos de cocaína, 75 pedras de crack e 24 porções de maconha, embalados para venda. Questionado, João não quis responder aos questionamentos dos policiais. Dado voz de prisão, o acusado foi algemado e conduzido até o Plantão Policial.

De rigor a procedência da ação penal.

Os relatos seguros, coesos e detalhados dos policiais militares permitem concluir com segurança que foram encontrados entorpecentes no interior da carenagem da motocicleta conduzida pelo réu, e esses eram evidentemente destinadas ao tráfico, pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento. Apesar de inúmeros questionamentos feitos pela Defesa, os policiais mantiveram seus relatos de forma

coerente, explicando de maneira detalhada o momento da abordagem do réu no dia dos fatos, bem como o encontro da droga no interior da carenagem da moto que ele conduzia.

Frise-se que os agentes não conheciam o réu e não teriam motivos para incriminá-lo injustamente. Tampouco há qualquer indício que mentiram com o intuito de prejudicar o acusado. Inclusive relataram que em duas oportunidades anteriores viram a mesma moto sem placas, mas não conseguiram abordá-lo, recordando-se dele após a prisão, momento em que identificaram que uma vez ele tinha sido abordado na frente de sua casa, porém sem nada de ilícito, tanto que foi liberado.

Ou seja, não se desincumbiu a Defesa do ônus de provar que os policiais ameaçaram o réu e o incriminaram injustamente.

As testemunhas de defesa não alteraram o quadro em desfavor do réu.

Igor disse que esteve com o réu pouco antes da abordagem, mas nada presenciou, ou seja, nada acrescentou ao conjunto probatório.

Bianca mencionou que presenciou toda a abordagem policial, que nada foi encontrado, que o réu estava sem mochila e que a polícia falou para a mãe dele que ele seria conduzido para a delegacia porque tinha "dado fuga".

Ocorre que o relato da testemunha de defesa Bianca é parcial e inverossímil, haja vista que num segundo momento de seu relato deixou escapar em suas declarações que os policiais disseram à mãe do réu que ele tinha drogas e também disse que saiu do local dos fatos para buscar a mãe do réu, de sorte que evidentemente não presenciou toda a ocorrência, não podendo afirmar que nada foi encontrado na moto.

Neste passo, o tráfico de drogas se confirmou em relação ao acusado, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Delineada a culpa, passo à análise da pena.

O acusado é primário, conforme se depreende de sua certidão para fins judiciais de fls. 155.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando que estava na posse de mais de 200g de droga de tipos diversos, o que é uma quantidade significativa, fixo sua pena-base 1/6 acima no mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, pela menoridade penal, retorno a pena ao patamar mínimo.

Na terceira fase, com fulcro no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11343/06, não havendo notícia de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, reduzo sua pena em 2/3, fixando-as definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal.

Frise-se que o fato de ter cometido uma conduta de traficância não significa, por si, que se dedique à atividade ou integre organização criminosa, de modo a configurar motivo idôneo para afastar a causa especial de diminuição da pena, tendo em vista que incumbe à acusação demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido é a lição Renato Brasileiro de Lima:

“(...) quanto ao ônus da prova acerca da presença (ou ausência) dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é certo dizer que, em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, incumbe à acusação comprovar a impossibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena, demonstrando que o acusado não é primário, não tem bons antecedentes, que se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa. Se não o fizer, a dúvida milita em favor do acusado, autorizando a aplicação da minorante. Afinal, como se observa a doutrina, fosse necessário que a defesa provasse os requisitos negativos de não se dedicar a atividade criminosa ou não integrar organização criminosa, haveria evidente violação à presunção de inocência, porquanto a prova negativa indeterminada é daquelas que se pode chamar de prova diabólica, tamanha a dificuldade em se desincumbir dela”

Considerando que, além do réu ser primário e sem antecedentes, o órgão acusador não demonstrou elementos concretos que indiquem que se dedicava ou integrava organização criminosa, a aplicação da causa de diminuição é medida de rigor.

A alegação de que tráfico de entorpecentes ser comandado, via de regra, por organizações criminosas (multinacionais), não implica, necessariamente, que o acusado, flagrado pela primeira e única vez em conduta de traficância, integre tais organizações, porquanto devem ser comprovados os requisitos da estabilidade e da permanência.

Torno as penas acima definitivas pela ausência de outros elementos modificadores. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado JOÃO PAULO DE ASSIS ao cumprimento das penas 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no HC 118.533, pacificou o entendimento que o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime de natureza hedionda.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observo que há decisão do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 97.256, que redundou na edição da Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, suspendendo a proibição que constava do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para aplicação da benesse, deixando a matéria ao prudente arbítrio do juiz, que analisará, no caso concreto, sua adequação como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

In casu, considerando o tempo de pena imposto, a primariedade do acusado, e a quantidade de droga apreendida, revisando o entendimento adotado há anos, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e observados os critérios de individualização da pena, vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, consoante disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III, e artigo 77, caput, inciso III, do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo das penas substituídas, em entidade a ser definida pelo juízo da execução, além da prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário-mínimo em favor de entidade também a ser definida pelo juízo da execução.

Em caso de descumprimento do benefício, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Poderá o réu recorrer em liberdade em face da pena imposta.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, declaro o perdimento de bens e valores em favor da FUNAD, bem como proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA